

0064385-79.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 199/2015 - 25º Distrito Policial - Parelheiros

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYARA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

Cuida-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0064385-79.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0064385-79.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 199/2015 - 25º Distrito Policial - Parelheiros

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYARA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

Cuida-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de MAYARA RODRIGUES pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, III, todos da Lei. 11.343/2006, porque no dia 20 de junho de 2015, às 9h40 minutos, na penitenciária Parelheiros situada na avenida Noel Nutels, número 100, a ré trazia consigo, para fins de tráfico de entorpecentes, 19g de maconha contendo tetrahydrocannabinol (THC) para a entrega a consumo de detentos, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2020, às fls. 180.

Resposta à acusação às fls. 140/146.

Audiência de instrução debates e julgamento.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu.

A Defesa, por sua vez, pleiteou no mérito a ausência de materialidade delitiva, sustentando ausência de laudo toxicológico definitivo, e a ilicitude da prova colhida em revista íntima.

Sentença proferida em fls. 211/212.

Recurso de Apelação interposto pela Defesa em fls. 225/254.

Contrarrazões em fls. 257/273.

Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça declarou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e determinou o retorno dos autos à Vara de origem para outra ser proferida, com apreciação das teses defensivas, em fls. 298/309.

Era o que tinha para relatar.

Vieram-me conclusos. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitiva, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pela ré amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, senão vejamos:

A materialidade restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência- fls. 04/09, pelo laudo de constatação das drogas número 318.803/2015 de fls. 19/21, pelas provas colhidas em sede policial bem como em juízo.

A testemunha Ana Maria, agente penitenciária na ocasião, não se recordou dos fatos.

A testemunha Amélia Angélica, agente penitenciária, também não se recordou sobre os fatos, mas afirmou que trabalhou na penitenciária, e que o procedimento de revista íntima era utilizado, pois no local não tinha aparelho de raio-x.

A ré em juízo ao ser indagada sobre os fatos exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Pois bem.

A ré não confessou os fatos, mas existe em seu desfavor o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, os laudos de constatação das drogas, além da farta e coesa prova documental. Observa-se que os documentos encartados aos autos são harmônicos, e corroboram que, no dia do crime, a ré trazia consigo 19 g de maconha para entregar ao seu companheiro - Hélio da Fonseca Nascimento- detento e custodiado na penitenciária em Parelheiros. Assim, durante a realização da revista íntima na acusada - técnica necessária para coibir esses tipos de delitos nas Cadeias Públicas - ante a ausência de scanner pessoal - foi encontrado um preservativo inserido na ré contendo as drogas acima descritas.

Com isso, é importante mencionar que a ré ao ser presa confessou a prática do delito, conforme documentos de fls. 06. Afirmou a ré, portanto, que trazia a aludida quantidade de drogas para entregar ao seu companheiro, preso na penitenciária em Parelheiros.

Ademais, convém mencionar que o depoimento das agentes penitenciárias - no momento do crime - é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Além disso, não se pode crer que as testemunhas quisessem, deliberadamente, incriminar a ré.

Considerando, assim, que o delito foi praticado no longínquo ano de 2015, entende-se que deve prevalecer o depoimento das testemunhas prestados no momento da prisão em flagrante da ré.

No mais, ante a confissão espontânea da acusada - em sede policial - e o relato coeso das agentes penitenciária, inexistem dúvidas sobre a autoria.

A materialidade também é inconteste, muito embora a tese defensiva alegue o contrário, especialmente no tocante a ausência do laudo de constatação definitivo das drogas, nota-se que a própria ré, ao ser presa, admitiu que a substância escondida em seu corpo era maconha, e a fazia a pedido do companheiro, que se encontrava segregado na penitenciária, mencionada nos autos. Se isto não bastasse, o Laudo Toxicológico de número 318.803/2015, de fls. 19/21, realizado por um expert (perito) no assunto, constatou a natureza ilícita da substância.

Assim, conjecturando que a prova em sede policial foi confirmada em juízo - não há que se cogitar ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Sendo então, a condenação medida de rigor.

A defesa suscitou algumas teses dignas de enfrentamento, vejamos.

DA ILÍCITUDO DA PROVA - REVISTA ÍNTIMA:

Conforme bem relatou as agentes penitenciárias, na época do delito, inexistia raio - x ou scanner pessoal na unidade prisional, sendo a revista íntima o procedimento padrão para evitar que os visitantes ingressassem nas unidades prisionais munidos de objetos ilícitos.

Ademais, como bem pontuou o representante do Ministério Público a revista íntima realizada na ré em nada ofendeu a sua integridade física ou moral, considerando que a acusada foi revista por agentes penitenciárias do sexo feminino, e em local adequado "reservado".

No mais, no caso em apreço, sopesando os valores supostamente colidentes, intimidade da acusada e a proteção/segurança estatal, entende-se que esta última deve prevalecer, eis que ilide a ocorrência de outros crimes no estabelecimento prisional, principalmente resguardando a segurança dos custodiados e dos funcionários que ali trabalham.

Nessa esteira, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já se deparou com situação fática análoga, onde proferiu o seguinte entendimento (grifo nosso):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.

POSSIBILIDADE DE REVISTA ÍNTIMA DE VISITANTE DE PRESÍDIO. NÃO OFENSA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INVASIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A alegação de incidência do óbice de admissibilidade do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 126 consubstancia inovação recursal, porquanto não levantada em momento oportuno por ocasião das contrarrazões ao recurso especial" (EDcl no AgRg no AREsp 1770430/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 5/4/2021).

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, para fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo.

3. No caso dos autos, a recorrida foi surpreendida com entorpecentes dentro de sua vagina, em procedimento de revista íntima ocorrida no interior de estabelecimento prisional, não havendo falar em ilegalidade, pois observados todos os parâmetros legais e constitucionais, sem a ocorrência de nenhum procedimento invasivo.

4. Agravo regimental desprovido.

Desta forma, tendo em vista que a revista íntima foi realizada conforme procedimentos padrões da Instituição penal, respeitando-se a dignidade da ré, em local apropriado e por agentes penitenciários femininas, não há que se falar em ilicitude de prova, não se olvidando a necessidade de se ponderar interesses constitucionais nesse cenário, onde o interesse público prevalece sobre o interesse individual, traduzindo aqui na tutela da segurança pública, notadamente, quanto ao

estabelecimento prisional, a fim de evitar a perpetuação de crimes com a entrada de objetos proibidos ou ilícitos no sistema penitenciário.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:

Inexistiu nulidade com relação ao reconhecimento em questão, eis que a ré foi presa em flagrante - sendo o flagrante devidamente homologado - eis que ausente qualquer vício. Além do que, a ré estava presente em audiência, e considerando o longo lapso temporal entre os fatos e a instrução criminal foi necessário que as testemunhas lembrassem da acusada - por meio da fotografia, anexada aos autos.

Outrossim, conjecturando que o reconhecimento não trouxe qualquer prejuízo para a ré, a nulidade não merece ser reconhecida. Inexistiu prejuízo, pois consoante explicado acima a autoria do delito em questão é inconteste.

Por fim, o reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo penal é uma mera recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Também, ainda, que o artigo 226 do diploma cima fosse regra legal, o magistrado pode reconhecer a autoria delitiva com base em outras provas nos autos, sem qualquer relação com o suposto reconhecimento viciado. No caso dos autos, conforme fundamentado alhures, entende-se incontroversa a autoria delitiva, especialmente pela prova documental já encartada no processo.

AUTO DE CONSTATAÇÃO:

A defesa sustenta a ausência de materialidade delitiva, ante a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo. Entretanto, tal tese não merece prosperar.

Verifica-se, que o documento de fls. 19/21 foi produzido por um Perito, expert no assunto, o qual constatou que a substância transportada pela ré era maconha. Aliado a isto, a ré, em sede policial, confessou que transportava entorpecentes.

Portanto, ainda que não presente a peça definitiva nos autos, de rigor salientar que o laudo toxicológico preliminar (fls. 19/21) mostra-se hígido e suficiente para comprovar a materialidade do delito em tela, tendo em vista que realizado por perito oficial competente, utilizando-se de técnicas e parâmetros científicos de aferição já consagrados na criminalística atual, e avalizado pela Polícia Científica do Estado de São Paulo.

Assim, de rigor acolher o laudo toxicológico preliminar como prova suficiente para comprovar a materialidade do delito imputado à ré, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pari passu, apenas para ilustrar a assertividade do Tribunal da Cidadania sobre esse tema, em julgado sob relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim disciplina sobre a validade do laudo toxicológico para fins de comprovação de materialidade (grifo nosso):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.

2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo

3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em

observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.

5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito.

6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial.

Portanto, considerando a fundamentação acima, entendo que a materialidade do delito está comprovada nos autos, ante a existência do laudo toxicológico prévio, afastando-se assim a tese defensiva.

Superada as teses defensivas passo a dosar a pena.

DA DOSIMETRIA.

Obedecendo o sistema trifásico e seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Na segunda fase da dosimetria presente a atenuante da menoridade relativa, mas por respeito ao enunciado sumulado número 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase da aplicação da pena reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11.343/06, e reduzo a pena da ré na metade, ou seja em 1/2. Este redutor justifica-se pois, apesar da pequena quantidade de maconha transportada pela ré, sua conduta tem alto grau de reprovabilidade- ao tentar fornecer drogas para presos já devidamente segregados - demonstrando, então, um total desprezo para com o sistema penal e com as institucionais em sentido amplo. Do mesmo modo, a ré demonstrou desprezo com sua própria vida/saúde- na medida em que poderia ir a óbito caso o pacote contendo as drogas estourasse e as substanciais entrassem em contato com seu organismo.

Ainda na terceira fase da dosimetria reconheço a majorante do artigo 40, III, do mesmo diploma legal - e aumento a pena em 1/3 - eis que a ré chegou a adentar no estabelecimento prisional com as drogas e quase obteve êxito em seu intento, sendo apenas desmascarada na revista íntima, razão pela qual fixo a pena definitiva em 3 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime aberto.

A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, e limitação de finais de semana. A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros, na forma do artigo 46 do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da execução na forma do artigo 149 da LEP. As tarefas deverão ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, até que venha a totalizar a pena imposta, na forma do artigo 46, § 3º, do Código Penal. Já a limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, nos termos do artigo 48 do

Código Penal.

A acusada poderá apelar em liberdade.

Dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar MAYARA RODRIGUES, qualificada nos autos, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 333 dias multa, que fixo no mínimo legal, a ser cumprida em regime aberto pela infração ao artigo 33, caput, combinado com o artigo 44, III, da lei 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade por igual período da pena corporal, e pela limitação de finais de semana pelo mesmo lapso temporal da pena corporal.

Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, observando-se o disposto no artigo 32, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legislativo, reservando-se material para contra-prova.

Transitada em julgado esta decisão, lancem-se o nome da ré nos livros dos culpados.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA